

0001165-62.2016.8.26.0474

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marco Antônio Costa Neves Buchala

Comarca: Potirendaba

Foro: Foro de Potirendaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Preto que Rozeney havia sido preso por tráfico de entorpecentes e lá em Rio Preto ele admitiu que era um dos autores do roubo na casa de Jurandir e que a outra pessoa era o Gustavo. Falou que as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico de Rozeney. Com mandado judicial conseguiram verificar que o acusado Gustavo utilizou a ERB de Nova Aliança no dia dos fatos. Que não sabe os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Potirendaba

Foro de Potirendaba

Vara Única

Rua Pedro Siqueira, 1.042, Potirendaba - SP - cep 15105-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001165-62.2016.8.26.0474 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001165-62.2016.8.26.0474

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROZENY DOMINGOS LOURENÇO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ROZENY DOMINGOS LOURENÇO, vulgo "Negjinho", e GUSTAVO DE SOUZA MIYAMOTO RODRIGUES, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Isto porque, conforme a denúncia de fls.450/452, no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 18h30min, na Rua José Fagliari, n. 154, centro, na cidade de Nova Aliança, nesta Comarca, os acusados, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos, subtraíram coisas móveis alheias, para si, consistentes em talonários de cheque, R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro, um revólver calibre 38, além de diversos cheques, preenchidos que somavam aproximadamente R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), mais R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em dinheiros, um aparelho de celular, uma aliança de ouro, um aparelho celular Samsung e mais R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), em dinheiro, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, tendo como vítimas Jurandir Barbosa de Moraes, Carlos Eduardo dos Santos Canado e Odair Marcato.

A denúncia foi recebida (fls.453). Os denunciados foram citados e apresentaram defesa prévia - fls. 561/563 e 606/613.

Mantido o recebimento da denúncia foi designada audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução, foram ouvidas as três vítimas, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma testemunha arrolada pela defesa e os réus foram interrogados(fls.633/634).

Declarada encerrada a instrução processual do feito, o Ministério Público manifestou-se em alegações, pugnando pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Postulou a condenação dos réus no regime fechado e observado o concurso formal de delitos (fls.644/651).

O ilustre defensor do corréu Gustavo de Souza Miyamoto Rodrigues apresentou as alegações finais (fls. 656/662), e requereu a absolvição por falta de provas de autoria. Alternativamente , aplicação da pena no regime aberto.

O ilustre defensor do corréu Rozeney Domingos Lourenço, por sua vez, manifestou-se em alegações finais (fls.663/673). Falou sobre a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado ; ilegalidade da prisão ; absolvição por falta de provas para condenação. Alternativamente , pela fixação do regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

Não havendo preliminares, passo diretamente à análise do mérito da ação penal proposta pelo Ministério Público contra os acusados imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso , II e § 2º A , inciso I , por três vezes , na forma do artigo 70 , todos do Código Penal.

Inicialmente esclareço ao i. Defensor do acusado Rozeney (fls.663/673), que o mesmo não se encontra preso em decorrência deste processo. O acusado Rozeney está preso em decorrência de outro delito(outro processo) em outra Comarca. Desse modo , não é devido o pedido de liberdade formulado pelo d. Defensor nestes autos.

De início, impõe-se registrar que o art. 155 do Código de Processo Penal, em razão do advento da Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008, passou a ter a seguinte redação: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Portanto, de acordo com a nova redação do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Nesse sentido, conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 359):"Limitação moderada em relação à investigação inquisitiva: a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos. O julgador jamais pôde basear sua sentença condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela

jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase de investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. (...)"

Quanto a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico formulado pelo i. Defensor (fls.663/673), tal pretensão merece acolhimento.

As vítimas apenas reconheceram fotograficamente e em solo policial (fls.49/51) o acusado Rozeney, ocasião na qual não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, cabe rememorar que o Superior Tribunal de Justiça mudou seu entendimento quanto ao valor probatório do reconhecimento pessoal efetuado em desconformidade com a prescrição legal, passando a compreender o seguinte:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 2. A Vítima, única depoente presencial dos fatos a ter sido ouvida em juízo, mais de um ano depois da prática da conduta, tão somente ratificou o que já havia afirmado em sede policial, quando houve, por ela, o reconhecimento fotográfico do Paciente. (...) 4. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inobservância do devido regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, nos termos da orientação consagrada no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (STJ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 6. Ordem de habeas corpus concedida, para restabelecer os efeitos da sentença absolutória. (HC 617.717/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021- grifo nosso)

Visto isto, não houve renovação do reconhecimento pessoal em juízo, mas verdadeira incerteza por parte dos ofendidos.

Vejamos :

A vítima Jurandir Barbosa de Moraes (fls.633/634), que relatou todo o assalto e a violência sofrida , os bens que foram subtraídos , sem fazer o reconhecimento pessoal dos acusados em audiência. Falou sobre características físicas deles, sem conseguir afirmar com certeza.

A vítima Odair Marcato , (fls.633/634), igualmente relatou toda a violência que sofreu no assalto, chutes , inclusive com fratura de uma costela , os depois que foram subtraídos , sem fazer o reconhecimento pessoal dos acusados em audiência.

A vítima Carlos Eduardo dos Santos Canado (fls.633/634), igualmente relatou que foram assaltados quando estavam dentro da casa , quando os ladrões entraram armados empunhando revólver, que foram rendidos e agredidos. Falou dos bens que foram subtraídos , porém igualmente alegou que não tem condições de reconhecer os acusados. Que também não fez o reconhecimento na polícia.

A testemunha Marcos Rogério Costa , investigador de polícia , ouvido às fls. 633/634, relatou que participou da investigação. Falou sobre o assalto que lhe foi relatado pelas vítimas e que através das câmeras de vigilância da região conseguiram identificar o veículo e a placa que estava perto da residência da

vítima. Chegaram na pessoa de Fábio que moravam em Rio Preto. Algum tempo depois foram informados por policiais de São José do Rio Preto que Rozeney havia sido preso por tráfico de entorpecentes e lá em Rio Preto ele admitiu que era um dos autores do roubo na casa de Jurandir e que a outra pessoa era o Gustavo. Falou que as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico de Rozeney. Com mandado judicial conseguiram verificar que o acusado Gustavo utilizou a ERB de Nova Aliança no dia dos fatos. Que não sabe os motivos das imagens das câmeras não estarem anexadas nos autos.

A testemunha Paulo Osmar Rizzo Júnior, investigador de polícia, ouvido às fls. 633/634, igualmente participou das investigações. Disse que procuraram as imagens de câmeras e descobriram um Fiat Stilo, circulando com duas pessoas pela cidade, além das duas pessoas que adentraram no imóvel da vítima para assaltar. Disse que a polícia de Rio Preto acabou prendendo Rozeney por tráfico naquela cidade e ele confessou o roubo e apontou Gustavo como coautor. Que os indivíduos que adentraram na casa estavam armados e com o rosto descoberto. Disse que as vítimas fizeram o reconhecimento na fase policial.

Por fim, a testemunha Mário Jesus Damião, ouvido às fls. 633/634, relatou que conhece Gustavo e que ele trabalhava no escritório de contabilidade e morava em São José do Rio Preto. Disse que Gustavo tinha um veículo Stilo. Que hoje Gustavo mora no Japão e nunca ouviu falar de envolvimento dele com delitos.

Quanto interrogados, os acusados negaram a prática do delito.

O acusado Gustavo de Souza Miyamoto Rodrigues, ouvido às fls. 633/634, negou veementemente o delito. Falou que está no Japão há três anos e que na época emprestou o veículo para uns rapazes do bairro, mas não estava com ele no dia dos fatos. Disse que seu irmão conhecia Rozeney e por isso emprestou o carro. Falou que nunca esteve em Nova Aliança e que seu celular havia sido perdido quando estava indo pescar. Falou sobre os apelidos dos rapazes e que não recebeu nada pelo empréstimo do veículo.

O acusado Rozeney Domingos Lourenço, ouvido às fls. 633/634, igualmente negou a prática do delito. Falou que ficou preso 19 anos e que os policiais não queriam ele no bairro. Falou que estava trabalhando na reciclagem e que os policiais invadiram sua casa e disseram que estavam envolvido em um assalto em Nova Aliança. Disse que não conhece Nova Aliança e que os policiais pegaram uma bolsa no carro com drogas e disseram para sua mãe que tinham encontrado essa droga. Disse que em momento algum assumiu o roubo e nem conhece Gustavo direito, apenas de vista. Sabe que ele tinha um veículo Stilo, cor clara. Que não sabe dirigir.

Mesmo na fase policial não há nenhuma versão do acusado Rozeney confessando o delito e imputando a Gustavo a coautoria. Pelo contrário, na fase policial o acusado Rozeney declarou que se manifestaria somente em juízo (fls.206).

Portanto, a versão dos policiais civis de que o acusado Rozeney confessou a autoria do delito não restou comprovada.

Na fase do artigo 402 do CPP (fls.633), restou determinado que a expedição de ofício a Delegacia de Polícia de Nova Aliança, a fim de que juntasse aos autos as IMAGENS DAS CÂMERAS QUE TENHAM FILMADO O VEÍCULO no dia dos fatos. Em resposta a autoridade policial informou que não possuía as imagens, respondendo negativamente ao pedido (fls.640).

Desse modo, encerrada a instrução, observa-se que a ação penal merece ser julgada improcedente. Observam-se nos autos duas versões antagônicas: uma apresentada na denúncia atribuindo aos acusados a prática do roubo; outra, dos acusados que negaram veementemente a prática do delito. Poderiam existir indícios que

justificassem a propositura da ação penal contra os acusados. Todavia, tais indícios são insuficientes para embasar um decreto condenatório. Na verdade, não restou comprovada a autoria e efetiva participação dos acusados no evento, havendo dúvida fundada nos autos sobre a efetiva participação deles no delito. Tais dúvidas, por si só, impedem um decreto condenatório e são favoráveis aos acusados.

Assim, tem-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação”(TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Como se tem decidido, RJDTCRIM 6/35: “Decisão pela dúvida em favor da sociedade-Inadmissibilidade . Ressalvado o julgamento específico das revisões criminais, em Direito Penal a dúvida sempre favorece ao sentenciado, assim, no processo de conhecimento como no de execução da sanção penal”.

Por oportuno, em regra primeira do Processo Penal sobre o ônus da prova , que sempre vale a pena recordar: “Não é o réu que tem o ônus de fazer prova defensiva apta a exculpar-se; à acusação é que incumbe demonstrar a sua culpa diante da presunção da inocência, garantida constitucionalmente” (RJDTCRIM 6/136).

Insuficiência de prova não significa a inexistência de prova alguma, mas que não foram carreados aos autos elementos suficientes para convencer o Juiz acerca da verdade real da autoria e/ou materialidade do fato atribuído aos réus. Em outros termos e para melhor objetivar os conceitos doutrinários, presente estado de dúvida sobre a autoria e/ou materialidade do delito; ou quando houverem informações contraditórias sobre a presença ou não , do agente no local do crime, quando os elementos afirmativos e negativos se equivalem e “O espírito vacila, diante dos motivos opostos que se apresentam ...”, de tal sorte a não permitir a prevalência de uns sobre outros, se está a frente a hipótese de insuficiência de provas , que será típica do chamado non liquet .

Em suma, a verdade real não foi alcançada. Assim, um decreto condenatório nestas condições é temerário, já que poder-se-ia estar condenando um inocente.

Já se decidiu que, “no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do Julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio”(RT vol.619/267).

Por fim é sempre bom ressaltar e relembrar que “... o processo penal não é apenas um meio para se alcançar a condenação do acusado de violação de normas incriminadoras, mas , de maneira muito expressiva , instrumento de garantia da liberdade ambulatoria do acusado e das garantias democráticas asseguradas na Constituição. E o guardião dessas garantias é o Juiz”(Ap.nº 1.020.047/2, 12ª Câmara, rel. Juiz Ary Casagrande, j. 29.07.96, v.u .).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal proposta pelo Ministério Público para ABSOLVER ROZENY DOMINGOS LOURENÇO , já qualificado, e GUSTAVO DE SOUZA MIYAMOTO RODRIGUES, já qualificado , com incursos no 157, § 2º, inciso , II e § 2º A , inciso I , por três vezes , na forma do artigo 70 , todos do Código Penal. Fundamento a absolvição dos acusados no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações devidas, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio OAB/Defensoria Pública e arquivem-se os autos .

P.I.C.

Potirendaba, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA